

0101310-40.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... adicionou que, em operação para coibir o tráfico de drogas, realizaram uma campanha e visualizaram a ré em atitude típica de tráfico de drogas. Em uma bolsa apreendida na posse dela, encontraram porções de cocaína e também quantia em dinheiro. Não se recorda se ela admitiu a traficância e quanto tempo durou a campanha. Não realizaram filmagens ou fotografias. Não se recorda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0101310-40.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0101310-40.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 5062/2016 - 7º

Distrito Policial - Lapa, 866/2016 - 7º Distrito Policial - Lapa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIDIA PATRICIA BESRUTCHKA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

ELIDIA PATRICIA BESRUTCHKA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no dia 29 de novembro de 2016, por volta das 21h40, na Rua Willian Speers, altura do numeral 892, região da Lapa de Baixo, nesta Comarca da Capital, foi surpreendida por policiais civis quando trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 5 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em plásticos, com peso líquido de 3,7 g (três gramas e sete decigramas - auto de exibição e apreensão acostado às fls. 10/11,); e a quantia de R\$ 71,00 (setenta e um reais), substância esta entorpecente, capazes de determinar dependência física ou psíquica em seus usuários, sem autorização e/ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 11) e, posteriormente, às perícias químico-toxicológicas (fls. 171/172).

A denúncia foi recebida (fls. 103).

A ré foi citada por edital (fls. 138/139) e posteriormente devidamente citada virtualmente (fls. 142) e apresentou defesa prévia (fl. 146). Após, o recebimento

da denúncia foi ratificado (fls. 147/148).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas. Por fim, a acusada foi interrogada.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requereu o aumento na primeira fase dosimétrica em razão dos maus antecedentes; na segunda fase, pediu o reconhecimento da agravante da reincidência. Por fim, pediu a fixação do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para a do art. 28, da Lei nº 11.343/06 ou, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da confissão espontânea em solo policial e, conseqüentemente, a sua compensação com a agravante da reincidência.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que a acusada no dia 29 de novembro de 2016, por volta das 21h40, na Rua Willian Speers, altura do numeral 892, região da Lapa de Baixo, nesta Comarca da Capital, foi surpreendida por policiais civis quando trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 5 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em plásticos, com peso líquido de 3,7 g (três gramas e sete decigramas - auto de exibição e apreensão acostado às fls. 10/11,); e a quantia de R\$ 71,00 (setenta e um reais), substância esta entorpecente, capazes de determinar dependência física ou psíquica em seus usuários, sem autorização e/ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais do DECAP atuavam no combate ao tráfico de entorpecentes na região da Lapa de Baixo, sabidamente conhecida por disseminação de drogas, e mais precisamente naquele local, ali permaneceram durante certo tempo em "campana", quando puderam observar que diversas pessoas se aproximavam de uma mulher, identificada posteriormente como sendo a denunciada, a ela entregavam dinheiro e pegavam algo, sugerindo ser drogas, e tais pessoas rapidamente se afastavam. Então, ante as fundadas suspeitas, os policiais resolveram efetuar a abordagem da denunciada e na averiguação foram encontradas em sua posse 5 (cinco) porções de Cocaína, acondicionadas em plásticos e a quantia de quantia de R\$ 71,00 (setenta e um reais). Na sequência, foi conduzida ao Distrito Policial e, no auto de prisão em flagrante, ao ser ouvida pela autoridade policial, confessou ser traficante, que registra antecedentes por tráfico de drogas e que ali onde foi detida, pouco antes, tinha vendido sete porções de cocaína.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação (fls. 10/11) e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 171/172), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 12), a acusada disse que estava trabalhando na "biqueira", pois queria ganhar um dinheiro. Confessou ser traficante de drogas; tem cinco filhos e estava grávida de seis meses; registra antecedentes por tráfico de drogas; estava na posse de cinco papелotes de cocaína e que iria vendê-los. Aduziu ainda que estava com R\$71,00, resultado da venda de sete papелotes de cocaína.

Ouvida em juízo, a ré confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. ELIDIA disse ter 43 anos e tem 6 filhos, sendo 3 menores de idade. Negou a prática criminosa. Disse que estava no local para a realização de programa e também para o consumo de drogas. As drogas encontradas eram para seu próprio uso. As pessoas que chegaram próximo de si eram pessoas conhecidas que apenas lhe cumprimentaram. Negou também que confessou a prática criminosa na Delegacia.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pela acusada restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os policiais civis Eduardo Fernandes Passeau e José Augusto Costantini Rezende narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 03 e 04), que, na desencadeada operação DECAP, receberam determinação superior para atuar no combate ao tráfico de drogas e diligenciaram até a Lapa de baixo, mais precisamente na Rua Willians Speer. Permaneceram em campanha, quando observaram uma mulher de meia idade e grávida, entregando papelotes para pessoas que transitavam pelo local. Aguardaram o melhor momento para abordagem, ocasião em que os usuários conseguiram se evadir e, em revista pessoal com a presa, ELIDIA PATRÍCIA, foram localizados cinco papelotes de cocaína e setenta e um reais. Indagada confessou ser traficante e registrar antecedentes por tráfico de drogas, confirmando ainda que havia vendido sete pinos de cocaína.

Em juízo, o policial Eduardo acrescentou que, à época, fazia um patrulhamento denominado DECAP. Em uma viatura descaracterizada, visualizaram a ré em atitude típica da venda de entorpecentes, já que pessoas dela se aproximavam rapidamente e iam embora após a entrega de algo. Realizaram a abordagem e encontraram, dentro da bolsa que ela trazia consigo, cocaína em porções individualizadas e também quantia em dinheiro. A acusada admitiu a prática delitiva informalmente. Não tinha abordado a acusada anteriormente ao ocorrido e se recorda de que ela havia relatado ser usuária de drogas. Quando realizou a abordagem da acusada, as pessoas que estavam ali próximo se evadiram. Visualizou, ao que se recorda, cerca de seis vendas de entorpecentes realizados pela ré durante o período de campanha. Não fizeram filmagem ou fotografias durante a observação, disse o policial.

Ouvido em juízo, o policial José Augusto adicionou que, em operação para coibir o tráfico de drogas, realizaram uma campanha e visualizaram a ré em atitude típica de tráfico de drogas. Em uma bolsa apreendida na posse dela, encontraram porções de cocaína e também quantia em dinheiro. Não se recorda se ela admitiu a traficância e quanto tempo durou a campanha. Não realizaram filmagens ou fotografias. Não se recorda também o número de pessoas. Não sabe se ela disse ser usuária de drogas, mas ela apresentava características relacionadas à prostituição. Não se recorda da distância que ficaram em campanha, mas foi próximo do local onde a acusada estava.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pela acusada.

Afora a confissão realizada pela acusada no Distrito Policial, os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram a realização de campana, ocasião em que puderam observar a ré realizando atos típicos de mercancia de entorpecentes: pessoas dela se aproximavam e iam embora, logo após troca mútua.

Diante deste contexto, procederam a abordagem, encontrando as drogas em posse da ré, mais precisamente no interior de sua bolsa, além de quantia em dinheiro.

Neste ponto, insta salientar que a alegação da ré - de que não confessou a prática criminosa na Delegacia de Polícia - carece de qualquer respaldo fático, pois, além de sua assinatura lançada às fls. 12, foi realizada perante Autoridade Policial e Escrivão de Polícia dotado de fé pública.

Outrossim, tem-se que sua negativa ofertada na fase processual restou absolutamente dissociada da prova oral colhida.

Cumprasseverar que os policiais prestaram relatos firmes e uníssonos, ambos aduzindo que não conheciam a acusada de outras abordagens, razão pela qual não tinha qualquer razão para acusa-la injustamente.

Ademais, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando não somente a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (05 porções de cocaína, peso líquido 3,7 gramas), como também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico. Além disso, houve a apreensão de dinheiro, o que colabora para a comprovação da conduta praticada pela acusada na mercancia ilícita de drogas.

Nessas mesmas circunstâncias, sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente por essas mesmas características de forma de acondicionamento dos tóxicos e quantia em dinheiro encontradas, e principalmente pelas circunstâncias fáticas de sua prisão .

Afasta-se, portanto, a pretendida absolvição.

Cumprassealtar que, mesmo que a acusada seja usuária de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso determinante para aferição da real destinação das drogas.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do

Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a acusada ostenta maus antecedentes por condenação transitada em julgado (fls. 99 - 050.07.068130-9/00 - controle 1277/2007, tráfico - 6ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - extinta a pena em 2009, fls. 162). Assim, a pena-base deve ser fixada acima do patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase, reconhece-se a presença da agravante da reincidência, ainda, específica (tráfico: fls. 101 - 35347/2010 - 25ª Vara Criminal de São Paulo - transitada para a defesa em 23.05. 2011), razão pela qual exaspero as penas em 1/5 (um quinto), ficando, assim, a pena provisória em 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois, além da acusada ter negado em juízo a prática criminosa, ainda retificou a confissão lançada na primeira fase da persecução penal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que a agente ostenta maus antecedentes por condenação também por tráfico e ainda é reincidente específica, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Assim, a sanção fica definida em 07 anos de reclusão e pagamento de 699 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes, a reincidência específica da ré e a hediondez do delito.

Neste sentido: "Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive,

momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador r Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR a acusada ELIDIA PATRICIA BESRUTCHKA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento do valor apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Uma vez que responde ao processo em prisão domiciliar, poderá a sentenciada recorrer no estado em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome da sentenciada no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.
P.R.I.C.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA